

1504260-61.2022.8.26.0362

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: PAULO ROGERIO MALVEZZI

Comarca: Mogi-Guaçu

Foro: Foro de Mogi Guaçu

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 02/12/2022

... de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico em razão da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, características típicas do tráfico varejista, além da apreensão de dinheiro de origem lícita não comprovada.

De se consignar que os guardas civis ainda acrescentaram que o local onde os fatos ocorreram é conhecido ponto de venda de drogas, o que foi confirmado pelo ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi-Guaçu

Foro de Mogi Guaçu

Vara Criminal

Rua José Colombo, 45, Mogi Guacu - SP - cep 13840-065

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1504260-61.2022.8.26.0362 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504260-61.2022.8.26.0362

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

CELSO ELIDIO BOTELHO

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). PAULO ROGERIO MALVEZZI

Vistos.

Celso Elídio Botelho foi denunciado e está sendo processado, porque no dia 01º de setembro de 2022, por volta das 15h40min, na Rua Tereza Georget Torres, 190, Distrito de Martinho Prado, pertencente a esta Comarca de Mogi Guaçu, nas imediações de praças públicas e de estabelecimentos de ensino, trazia consigo, para fins de tráfico e entrega a terceiros, 28 (vinte e oito) porções de cocaína, pesando aproximadamente 21 g, 12 (doze) porções de "maconha" pesando 18,7 gramas e 03 (três) porções de cocaína em forma de "crack", pesando 0,37g, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, e o fazia sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 110), apresentou defesa prévia (fls. 101/104) e a denúncia foi recebida aos 25 de outubro de 2022 (fls. 111/112)

Houve citação (fls. 159).

Durante a instrução, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado.

A representante do Ministério Público pugnou pela procedência da ação penal e condenação do acusado nos termos descritos pela denúncia.

A defesa alega, preliminarmente, nulidade da apreensão por ter sido realizada por guardas civis municipais. No mérito, requer a improcedência da ação, alegando que

as drogas não lhe pertenciam e afirmando que é apenas usuário. No caso de condenação, requer benesses quanto à pena aplicável.

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

No caso concreto, deve ser rechaçada a alegada nulidade decorrente da prisão efetuada pelos guardas civis municipais, pois as circunstâncias indicadas justificavam a ação dos guardas civis, na medida em que o guarda civil Henrique relatou que o local é ponto conhecido de venda de drogas, fato confirmado pelo acusado.

Mais do que isso, no caso concreto, os guardas civis presenciaram o contato do acusado com terceira pessoa, em local conhecido como ponto de venda de drogas, tendo o acusado tentado fuga, circunstâncias que justificavam a ação dos servidores municipais.

Desse modo, não apenas os guardas civis, mas qualquer do povo estava autorizado a realizar a prisão em flagrante, não havendo que se falar em nulidade capaz de gerar a nulidade da apreensão das drogas. Nesse sentido, em recente precedente, a Egrégia 3ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo decidiu que:

Não se sustenta a tese de nulidade da prova sob argumento de que os guardas civis não possuem atribuição de polícia judiciária ou de investigação criminal. Com efeito, embora constitucionalmente seja atribuída à polícia civil a função de polícia judiciária e à polícia militar o policiamento ostensivo, as guardas civis municipais, instituídas por leis com permissivo do § 8º, do art. 144, da Constituição Federal, exercem atividades de policiamento, com dever de manutenção da ordem pública e zelo da segurança dos munícipes. Assim sendo, no exercício de suas funções, os guardas civis metropolitanos que constatarem atividade criminosa têm o dever de realizar a prisão em flagrante, o que, aliás, é facultado a qualquer do povo, nos termos do art. 301, do Código de Processo Penal. Nesse sentido é o recente posicionamento do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E USO DE DOCUMENTO FALSO. PRISÃO FLAGRANCIAL ILEGAL. GUARDA MUNICIPAL PODE PROMOVER PRISÃO EM FLAGRANTE. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A primeira parte do art. 301 do Código de Processo Penal autoriza a qualquer do povo prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito. Desse modo, inexiste ilegalidade na prisão em flagrante realizada por guardas municipais. 2. Conforme compreensão da Sexta Turma desta Corte Superior, havendo fundada suspeita a configurar situação de flagrante delito, mostra-se lícita a abordagem pessoal feita pela Guarda Civil Municipal, que não atua, nessa hipótese, como polícia investigativa. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ, AgRg no Habeas Corpus nº 667.413 SP, Relª Minª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 1º/06/2021). "Não obstante, a realização de prisão em flagrante e revista pessoal por guardas municipais não encontra óbice na legislação e jurisprudência. Explico. Esta eg. Corte, há muito, firmou o entendimento de que, "Nos termos do artigo 301 do Código de Processo Penal, qualquer pessoa pode prender quem esteja em flagrante delito, de modo que inexiste óbice à realização do referido procedimento por guardas municipais, não havendo, portanto, que se falar em prova ilícita no caso em tela. Precedentes" (RHC 94.061/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 30/4/2018). Saliente-se, ademais, que, enquanto não cessada a permanência, haverá o estado de flagrância, o que possibilita a prisão, diga-se novamente, por qualquer do povo. (...) Ainda, tem-se que o artigo 144, § 8º, da Constituição Federal prevê, como órgão componente do sistema de segurança pública, a Guarda Municipal, verbis: "Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: (...) § 8º Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei." Apesar da função constitucional das guardas municipais serem restritas a proteção dos bens, serviços e instalações dos entes municipais, não se verifica, in casu, qualquer ilegalidade ou abuso de poder na sua atuação, tendo em vista que a prisão efetuada foi em flagrante, a qual poderia ser realizada até mesmo por qualquer do povo e sem

mandado, na forma do art. 301, do Código de Processo Penal, verbis: "Art. 301. Qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito." Nesse sentido, autorizada estava a prisão em flagrante no caso concreto. Portanto, não há falar, em situações como tais, em inexistência de denúncia anônima, de mandados de prisão, assim como dos de apreensão de material ilícito, pois tanto a prisão quanto a apreensão das drogas são mera consequência lógica da situação de flagrância. (STJ, Habeas Corpus nº 650.864 SP, Rel. Min. Felix Fischer, Decisão Monocrática, j. 21/05/2021). (Apelação Criminal n. 1501969-26.2020.8.26.0567, Relator Desembargador Jayme Walmer de Freitas, 3ª Câmara de Direito Criminal).

No mérito, a materialidade delitiva está demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 16/17); pelo auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 11/12); pelos laudos de exame químico-toxicológicos (fls. 68/70, 71/73, 134/136, 137/139 e 140/142), pelo laudo de local do fato (fls. 143/147) e por toda a prova oral colhido em juízo.

Henrique da Silva disse que, durante patrulhamento pelo distrito de Martinho Prado, passou por local conhecido por "predinhos". Avistou o acusado com objeto nas mãos e ele, ao avistar a viatura, tentou se evadir, mas foi abordado e submetido à busca pessoal. Localizou drogas diversas em seu bolso e o acusado confirmou que estava praticando o tráfico, afirmando também que o lucro seria utilizado para sustentar seu vício. Disse que a abordagem se deu porque o acusado estava em contato com outro indivíduo, que também foi abordado, mas nada localizado. Não conhecia o acusado e foi a primeira ocasião em que realizou sua abordagem. Disse que o local é conhecido como ponto de venda de drogas, inclusive no bloco onde o acusado estava. Em solo policial, o acusado Celso Elidio Botelho, assistido por advogado, afirmou ser usuário de maconha. Disse que trabalhou e recebeu a quantia de R\$ 80,00 em espécie. Estava no local dos fatos para adquirir drogas para seu consumo pessoal, mas, ao se aproximar dos traficantes que ali estavam, a viatura policial surgiu e os traficantes lhe jogaram uma bolsa e saíram correndo. Disse que também decidiu correr, mas foi capturado e a bolsa foi encontrada. No interior da bolsa havia drogas, mas o acusado não sabia o que exatamente estava dentro dela, nem a quantidade, pois somente estava no local para comprar. Afirma que já ficou um dia preso pelo delito de receptação e possui passagens anteriores por tráfico, mas que naquele dia esteve no local para comprar para seu uso pessoal.

Em juízo, o acusado disse que é usuário de drogas e estava no local para adquirir o entorpecente. Disse que não vende drogas. Afirma que os traficantes se evadiram quando notaram a presença da viatura e abandonaram a sacola contendo as drogas. Disse que pegou a sacola e, então, foi abordado.

Com efeito, o depoimento prestado pelos guardas municipais é digno de toda credibilidade, já que devidamente compromissados e inexistentes indícios de interesse dos servidores públicos em prejudicar pessoa inocente. De acordo com a jurisprudência:

PROVA - Depoimento policial - Eficácia - Mera condição de agente público que não torna a testemunha impedida ou suspeita - Precedentes - Recurso improvido. (Apelação Criminal n. 974.712-3/9-00 - Santos - 14ª Câmara Criminal - Relator: Sérgio Ribas - 01.03.2007 - V.U. - Voto n. 4.191).

No caso dos autos, as provas carreadas permitem a formação da convicção de que o acusado realmente se dedicava ao tráfico em razão da quantidade e diversidade das drogas apreendidas, características típicas do tráfico varejista, além da apreensão de dinheiro de origem lícita não comprovada.

De se consignar que os guardas civis ainda acrescentaram que o local onde os fatos ocorreram é conhecido ponto de venda de drogas, o que foi confirmado pelo acusado, que asseverou que o tráfico de drogas realmente ocorre naquele ponto.

Quanto à alegação do acusado de que as drogas apreendidas pertenciam a terceira pessoa, anoto que o guarda civil Henrique disse que havia uma única pessoa no local, que, aliás, estava em contato com o acusado e foi abordada, mas nada foi apreendido em seu poder.

Assim, não há nenhuma prova de que havia outras pessoas no local e que elas correram ao notar a aproximação da viatura, arremessando as drogas para o acusado,

fato que não foi informado pelo guarda civil Henrique da Silva, que nenhum motivo teria para ocultar tal circunstância.

Desse modo, inegável que o acusado incorreu no tipo penal descrito no art. 33 da Lei n. 11.343/06, que é misto alternativo, de modo que, comprovado que trazia consigo quantidade expressiva de drogas diversas acondicionadas de forma fracionada, deve ser dado como incurso naquele preceito legal. A esse respeito: "O crime de tráfico de entorpecentes é configurado ainda que não haja venda de tóxico, mas evidenciada somente a posse do produto destinado a consumo de outrem. Configurando crime de perigo abstrato, o tráfico não exige efetiva oferta da droga a terceiro, pois o bem jurídico tutelado é a saúde pública. É condenável a simples possibilidade de distribuição (gratuita ou onerosa) do entorpecente" (RT 776/663). "Ademais, é sabido que o tráfico de entorpecentes é delito de ação múltipla ou conteúdo variado cuja consumação se contenta com a aquisição, transporte, depósito, guarda ou simples porte da droga, desde que não seja para consumo pessoal. Daí não haver falar em mero auxílio ao uso de drogas, visto que a paciente foi flagrada na posse de maconha e cocaína. (STJ, HC 211.467/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, 6ª TURMA, julgado em 16/08/2011, DJe 31/08/2011).

Inviável o acolhimento do pedido desclassificatório sustentado pela defesa, na medida em que o acusado não logrou sequer demonstrar que ostentava condições financeiras para adquirir tão significativa quantidade de drogas diversas, a não ser dedicando-se ao comércio espúrio, valendo lembrar que o fato do réu ser usuário de cocaína não afasta a sua qualificação de traficante, ocorrendo a absorção do delito de porte para uso pelo de tráfico (TJMG, Ap. 1.0481.03.029037-5, Rel. Sérgio Braga, DJ de 1.12.2005).

Passo à dosagem da pena, em conformidade com o disposto nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal.

Em primeira fase, as circunstâncias judiciais são favoráveis ao acusado, de modo que fixo a pena-base em 5 anos de reclusão e pagamento de 500 dias-multa.

Em segunda fase, não há atenuantes a reconhecer, mas incide a agravante da reincidência, por força da condenação nos autos n. 2875-11 (fls. 127), de modo que majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 5 anos e 10 meses de reclusão e pagamento de 583 dias-multa.

Em terceira fase, incide a causa de aumento de pena prevista no artigo 40, III, da lei n. 11.343/06, já que o laudo pericial (fls. 143/147) revela que os fatos ocorreram existem praças públicas, o que evidentemente facilita a propagação do tráfico de drogas devido ao maior fluxo de pessoas.

Aliás, a lei não exige que aqueles sejam os locais especialmente visados pelo infrator, bastando a proximidade física. A esse respeito:

A traficância era exercida em local inequivocamente próximo das escolas "Zumira" e "Rubens Leme Asprino" (distava aproximadamente 800 metros da primeira e 490 metros da segunda - vide fls. 74/7), sendo que para a incidência da majorante referente ao artigo 40, inciso III, não exige a lei que o estabelecimento de ensino seja especialmente visado pelo infrator, bastando, tão somente, a proximidade física e o conhecimento dessa proximidade. (TJSP, Apelação n. 0004114-44.2011.8.26.0083, Relator Des. Geraldo Wohlers, julgado aos 26.2.2013, 3ª Câmara de Direito Criminal) Ainda sobre essa questão, o Col. Supremo Tribunal Federal já teve a oportunidade de se pronunciar no sentido de que "(...) O tráfico de drogas nas imediações de estabelecimentos de ensino é suficiente para incidência da causa de aumento de pena prevista no art. 40, III, da Lei 11.343/2006, independente de os agentes visarem ou não os frequentadores daquele local (...). Destarte, não procede a alegação da impetrante no sentido de que não há demonstrativo de relação evidente entre a conduta dos pacientes e as atividades desenvolvidas pelos estabelecimentos de ensino, uma vez que é irrelevante o fato de haver ou não intenção dos acusados de atingir os frequentadores do estabelecimento. Para incidência da mencionada causa de aumento de pena, basta a proximidade física do local onde o tráfico estava sendo praticado e o estabelecimento de ensino, o que ficou corretamente assentado pelas instâncias ordinárias." (HC 116.929/SP, 1ª Turma, relator Min. Luiz Fux, julgado aos 15.10.2013).

No mesmo sentido, posiciona-se o E. Superior Tribunal de Justiça, que em precedente

desta Comarca decidiu que: No entanto, o Superior Tribunal de Justiça possuía entendimento no sentido de ser desnecessária, para a incidência da majorante do artigo 40, III, da lei de drogas, a comprovação de que o comércio de ilícito de substâncias entorpecentes vise atingir os alunos do estabelecimento, bastando, para sua incidência, que a prática da traficância tenha ocorrido nas imediações da escola (RESP n. 1.774.414/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 22.2.2019).

Por estes fundamentos, majoro a pena em 1/6, resultando pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e pagamento de 680 dias multa.

Ainda em terceira fase, inviável a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/06, pois o acusado é reincidente, o que impossibilita a incidência da benesse.

Cada dia-multa será calculado no mínimo legal.

A pena privativa de liberdade deverá ser cumprida em regime inicial FECHADO, porque o acusado é reincidente.

Inviável a substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, em razão do total da pena imposta e da reincidência do agente.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Celso Elídio Botelho à pena privativa de liberdade de 6 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 680 dias-multa, cada qual no mínimo legal, dando-o como incurso no art. 33, caput, c.c. art. 40, III, da Lei nº 11.343/06.

O réu respondeu ao processo no cárcere e com a condenação ficam reforçados os motivos que ensejaram a custódia cautelar, razão pela qual lhe nego o direito de recorrer em liberdade, anotando que é reincidente, o que revela que sua liberdade configura risco concreto à ordem pública. Recomende-se na prisão, com expedição de ofício.

Decreto o perdimento do numerário apreendido, pois não comprovada sua origem lícita e porque consequência lógica da condenação imposta.

Expeça-se certidão de honorários ao defensor dativo.

Deixo de aplicar o quanto disposto no artigo 387, §2º, do Código de Processo Penal, pois o acusado não atingiu o lapso temporal para eventual progressão de regime.

Concedo a gratuidade da justiça.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do réu no rol dos culpados.

PRI.

Mogi Guacu, 01 de dezembro de 2022.

Paulo Rogério Malvezzi

Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA